

1500679-06.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500679-06.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124686/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÉSAR RENATO VERDICCHIO

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 05 dias do mês de setembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dra. Paulo Kishi e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel. Apresentados o acusado CÉSAR RENATO VERDICCHIO, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo e Roger da Silva Olivencio Mendes.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, CESAR RENATO VERDICCHIO foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 07 de maio de 2022, por volta de 19h50min., na avenida Lourenço Filho, nº 116, bairro CECAP, nesta cidade e comarca, trazia consigo 30 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17) e laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, policiais militares patrulhavam pelo local, conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas, quando avistaram e suspeitaram do denunciado que, ao perceber a aproximação da polícia "tentou sair disfarçadamente do local". Feita abordagem de praxe, em poder do denunciado foram localizadas 30 porções de cocaína no bolso da blusa, além da quantia de R\$ 226,00, em notas diversas.

Instado, informalmente, ele confessou o crime.

As circunstâncias apuradas, local da prisão e apreensão de significativa quantidade de droga e de dinheiro evidenciam que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas

Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo, policial militar, narrou "no dia de hoje, por volta das 19:50 horas, estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Cecap, com vistas a coibir o tráfico de drogas no bairro, quando a equipe policial adentrou a Avenida Lourenço Filho, altura do numeral 116, local já conhecido por intenso comercio de drogas, onde os policiais visualizaram na via publica um indivíduo que ao avistar a equipe policial tentou sair disfarçadamente do local, fato este que chamou a atenção da equipe policial. Diante da fundada suspeita, este indivíduo foi abordado e em revista pessoal foi localizado no bolso de sua blusa 30 porções de substância aparentando ser COCAÍNA e o valor de R\$ 226,00 reais em notas diversas. Este indivíduo foi identificado com CESAR RENATO VERDICCHIO, que indagado informalmente pelos policiais confessou a prática do tráfico no local. Por fim, alega o policial que houve a necessidade de usar algemas para evitar fugas. Assim, tendo em vista a grande quantidade de drogas que foi apreendida em seu poder, aparentando ser do tráfico, o policial deu voz de prisão em flagrante, declarando seus direitos constitucionais e o encaminhou a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária" (fls. 05/06).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial.

Roger da Silva Olivencio Mendes disse "no dia de hoje, por voltadas 19:50 horas, estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Cecap, com vistas a coibir o tráfico de drogas no bairro, quando a equipe policial adentrou a Avenida Lourenço Filho, altura do numeral 116, local já conhecido por intenso comercio de drogas, onde os policiaei visualizaram na via publica um indivíduo que ao avistar a equipe policial tentou sair disfarçadamente do local, fato este que chamou a atenção da equipe policial. Diante da fundada suspeita, este indivíduo foi abordado e em revista pessoal foi localizado no bolso de sua blusa 30 porções de substância aparentando ser COCAÍNA e o valor de R\$ 226,00 reais em notas diversas. Este indivíduo foi identificado com CESAR RENATO VERDICCHIO, que indagado informalmente pelos policiais confessou a prática do tráfico no local. Por fim, alega a policial que houve a necessidade de usar algemas para evitar fugas. Assim, tendo em vista a grande quantidade de drogas que foi apreendida em seu poder, aparentando ser do tráfico, o policial deu voz de prisão em flagrante, declarando seus direitos constitucionais e o encaminhou a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária" (fls. 07/08).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. Já havia abordado o réu em outras oportunidades, mas foi a primeira vez que apreendeu drogas.

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo, o réu alegou que é caminhoneiro. É dependente químico. Como as empresas exigem o exame toxicológico chamava um amigo. Já foi condenado por crime de roubo e estava cumprindo pena. Estava no local com um pouco de droga. Não estava traficando. Havia consumido um pouco de droga no local. Eram seis porções para o seu consumo. Os policiais acharam 30 porções de droga e disseram que eram suas. O dinheiro apreendido era do seu serviço. Havia comprado 8 porções de droga e consumido 2. Não sabe aonde os policiais achou o restante da droga. Nunca foi abordado por estes policiais. Faz uso de crack e cocaína.

Diante do todo apurado, há provas suficientes que demonstram que o réu foi o autor do delito imputado na inicial.

A narrativa dos policiais foi firme e uníssona em confirmar que passavam pelo local, conhecido pelo intenso tráfico ilícito de drogas, quando avistaram e suspeitaram do réu que, ao perceber a aproximação, tentou evadir-se disfarçadamente. Feita abordagem, em poder dele foram localizadas 30 porções de cocaína e a quantia de R\$ 226,00, em notas diversas. Informalmente, ele confessou o delito.

Assim, restou indubitável que ele foi autor do delito.

Os policiais não tinham motivos para incriminar o réu injustamente.

Pertinente salientar, que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais militares, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 05/05/2016) – Grifo nosso. A quantidade de porções individualizadas apreendida e montante em dinheiro apreendido, corroborada pelas palavras dos policiais e admissão informal do réu, evidenciam que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita.

Destarte, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena pode ser fixada no mínimo legal, pois ausentes circunstâncias desabonadoras do artigo 59, do Código Penal.

O réu é reincidente. Ausentes circunstâncias atenuantes, causas de aumento e diminuição.

O réu é reincidente, o que impede concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Outrossim, a quantidade de porções e dinheiro apreendidos evidenciam que ele dedicava-se ao crime em questão.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, César Renato Verdicchio, está sendo denunciado com incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 69-73), no dia 07 de maio de 2022, por volta de 19h50, na avenida Lourenço Filho, nº 116, bairro CECAP, nesta cidade e comarca de Piracicaba,

CESAR RENATO VERDICCHIO trazia consigo 30 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas. Ainda segundo a inicial acusatória, policiais militares patrulhavam pelo local, conhecido pelo intenso comercio ilícito de drogas, quando avistaram e suspeitaram do denunciado que, ao perceber a aproximação da polícia "tentou sair disfarçadamente do local". Feita abordagem de praxe, em poder do denunciado foram localizadas 30 porções de cocaína no bolso da blusa, além da quantia de R\$ 226,00, em notas diversas. Instado, informalmente, ele confessou o crime.

Na delegacia o policial militar Wanderson Elias Ramos Da Costa Azevedo, disse que: "Alega o Policial Militar, da ROCAM, ora condutor, que no dia de hoje, por volta das 19:50 horas, estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Cecap, com vistas a coibir o tráfico de drogas no bairro, quando a equipe policial adentrou a Avenida Lourenço Filho, altura do numeral 116, local já conhecido por intenso comercio de drogas, onde os policiais visualizaram na via pública um indivíduo que ao avistar a equipe policial tentou sair disfarçadamente do local, fato este que chamou a atenção da equipe policial. Diante da fundada suspeita, este indivíduo foi abordado e em revista pessoal foi localizado no bolso de sua blusa 30 porções de substancia aparentando ser COCAINA e o valor de R\$ 226,00 reais em notas diversas. Este indivíduo foi identificado com CESAR RENATO VERDICCHIO, que indagado informalmente pelos policiais confessou a prática do tráfico no local. Por fim, alega a policial que houve a necessidade de usar algemas para evitar fugas. Assim, tendo em vista a grande quantidade de drogas que foi apreendida em seu poder, aparentando ser do tráfico, o policial deu voz de prisão em flagrante, declarando seus direitos constitucionais e o encaminhou a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária" (fls. 5-6).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Roger Da Silva Olivêncio Mendes (fls. 7-8).

Interrogado em solo policial, César exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 9-11).

Às fls. 34-35, juntadas folha de antecedentes e certidão de objeto e pé que indicam a reincidência do requerido (processo nº. 0000127-57.2018.8.26.0599, art. 157, pena de 4 anos e 8 meses, trânsito em julgado em 22/05/2018).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de fls. 98-100.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

Ouvido, inicialmente, o policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo. Relatou que estava em patrulhamento e passou por local conhecido pelo tráfico, em frente a um supermercado. Por ele ter demonstrado nervosismo, decidiram abordá-lo. Encontraram em sua posse 30 porções de cocaína e dinheiro. Ele disse que "perdeu" e confessou a traficância. O local tem um bar e um recuo no terreno. O ponto de tráfico é nesse recuo. Essa área é bem movimentada, quase em frente a um supermercado, e seria um local para as pessoas comerem, o bar usa para colocar mesas e cadeiras, outras pessoas passam. Cesar já foi abordado em outras vezes, já o conhecia. Mostrou nervosismo porque virou rapidamente e tentou sair do local. As outras abordagens ocorreram no mesmo local, mas nessas ocasiões ele apenas tinha dinheiro. Havia outras pessoas no local, que é movimentado.

Em seguida, ouvido o policial militar Roger da Silva Olivêncio Mendes. Acrescentou às informações prestadas pelo companheiro de farda que o réu, ao ser avistado, estava em pé.

Por fim, interrogado o acusado César Renato Verdicchio. Contou que é caminhoneiro e usuário de drogas. Era o aniversário da filha e bebeu um pouco demais. Foi ao bar comprar drogas. Comprou 8 porções. Usou um pouco e tinha mais um pouco no bolso. Os policiais lhe abordaram. Perguntaram se tinha passagem. Acharam as 6 porções que restavam em seu bolso. Os policiais disseram que, o que achassem no local, seria dele. O menino que estava vendendo, fugiu. Eles acharam mais droga e imputaram a ele. Tem 47 anos, nunca traficou. O dinheiro que tinha consigo era fruto do seu trabalho. As 8 porções eram de cocaína, custaram R\$10,00/cada. Usou parte da droga no banheiro do bar. Sobraram 6 porções. Quando os policiais chegaram, não tentou

correr. O menino que estava traficando saiu do local. Na verdade, os policiais foram direto nele. Óbvio que se assustou, é trabalhador, mas tinha droga no bolso para o seu uso. O menino se aproveitou e fugiu. Tinha mais gente no bar. Foi abordado na parte de fora, perto de uma mesa. Não viu onde os policiais acharam o restante da droga, só viu quando um deles veio com a droga na mão e falou com o outro. Nunca foi abordado por esses policiais, não sabe o porquê disseram que o conhecia. Já usou crack, conseguiu parar, mas não consegue parar com a cocaína. Já foi internado duas vezes.

- DA NULIDADE EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL

PRELIMINARMENTE a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade em razão da ilegalidade da abordagem por uma dita "atitude suspeita", da revista pessoal NO RÉU e, conseqüentemente, de todos os atos decorridos na continuidade de sua prisão. Isso porque toda a ação policial que resultou na prisão em flagrante teve origem em uma abordagem e uma revista pessoal ilegal, prova ilícita que contamina todas as outras provas dela decorrentes (art. 5º, LVI, da Constituição e art. 157, caput e §1º, do CPP).

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares efetuaram a busca pessoal no réu alegando que este aparentava estar "nervoso". É notório que tal motivo está atrelado ao ponto de vista meramente pessoal dos policiais/guardas. Tal busca relatada pelos agentes de segurança pública ofende, de forma manifesta, o disposto no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, que somente autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. E, este também é o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que a percepção de nervosismo por parte dos agentes públicos não é elemento que autoriza a busca pessoal:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos.

2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

(STJ, Resp 1.961.459, 6ª Turma, rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 02/04/2022)

Assim, o fato de uma pessoa apresentar suposto nervosismo em via pública não configura, de modo algum, e tampouco justifica a fundada suspeita exigida pelo art. 240, §2º, do CPP, que deve ser entendida como a existência de indícios concretos de cometimento de crime, e não meras suposições pessoais de policiais/guardas civis. É inevitável, portanto, reconhecer a ilicitude de todas as provas que deram origem ao flagrante, bem como todas em decorrência de tal ato, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP – teoria dos frutos da árvore envenenada, que determina que a ilicitude dessa prova originária contamina todas as outras provas que são dela originárias, e conseqüentemente, não havendo provas a serem consideradas, a absolvição por insuficiência probatória.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Eventual sentença de condenação estaria embasada nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Ademais, os policiais informaram que havia mais pessoas no local,

sendo certo portanto que seria possível a produção de provas testemunhais isentas. Caberia à acusação trazer aos autos tais provas, mas esta não se desincumbiu do seu onus probandi.

Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

O réu relatou que tinha consigo apenas 6 porções de cocaína e já tinha consumido outras duas.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em

hospitais psiquiátrico: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos”, de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína.” (p. 8-9 do Acórdão)”.

É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida do acusado não é excessiva, corroborando as declarações do acusado no sentido de que é usuário.

Isso posto, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: “A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais” (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não tendo sido demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

“PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo” (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição, tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional por ferir o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: “Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]” (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: “O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação

e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, fixada tal premissa, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas. Isso posto, diante da alegação ora invocada, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, afastando-se a imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas, o que torna imperiosa a sua absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Porém, rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, a reincidência deve ser compensada com a confissão, ainda que informal. sendo ambas as circunstâncias preponderantes (art. 67. CP).

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão

preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pela MM.Juiza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

CESAR RENATO VERDICCHIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de maio de 2022, por volta de 19h50, na Avenida Lourenço Filho, n. 116, bairro CECAP, nesta cidade e comarca, trazia consigo 30 porções de cocaína, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares patrulhavam pelo local, conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas, quando avistaram e suspeitaram do réu que, ao perceber a aproximação da polícia "tentou sair disfarçadamente do local".

Feita abordagem de praxe, em poder do réu foram localizadas 30 porções de cocaína no bolso da blusa, além da quantia de R\$ 226,00, em notas diversas. Instado, informalmente, ele confessou o crime.

As circunstâncias apuradas, local da prisão e apreensão de significativa quantidade de droga e de dinheiro evidenciam que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 72/73), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 74).

Notificado (fls. 81), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu pela concessão de liberdade provisória (fls. 85/88).

A denúncia foi recebida, sendo designada audiência (fls. 101/103). O réu foi citado (fls. 120).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Alegou a Defesa, também, que a prova é nula, na medida em que os policiais militares não poderiam abordar o réu, sem que houvesse suspeita na sua conduta. Ocorre, contudo, que os policiais militares suspeitaram do réu, que estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, onde outras várias pessoas foram detidas pela prática desse crime e onde o próprio réu já tinha sido abordado outras vezes, e ainda tentou se desvencilhar da abordagem. Havia, portanto, justa causa à abordagem policial

E mais, tratando-se de abordagem na via pública, há entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade de justa causa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por policiais militares quando, ao avistar os agentes, correu para dentro de sua residência. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 3. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial" (REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017). 4. No caso, o ingresso dos policiais na residência do Paciente foi amparado tão somente no fato deste ter adentrado rapidamente em sua residência ao

avistar os agentes, o que por si só não caracteriza elemento objetivo apto a legitimar a medida. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.352/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022) - grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA DO AGENTE E DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 2. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 3. Hipótese em que a simples fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 132.343/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021) - grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. (...) 12. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial. (...) 15. Recurso provido, ex officio, para reconhecer, nos Autos n. 0024.19.100.161-9, a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP, determinando, assim, a sua imediata soltura. (RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

II - Do mérito

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 17, na fotografia de fls. 18, no laudo de constatação de fls. 21/22, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 99/100, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu calado (fls. 10).

Em Juízo, o réu disse que estava no local e bebeu um pouco demais. Foi ao bar, pegou 08 porções de cocaína, por R\$ 10,00 cada uma, de um rapaz que fica nesse local vendendo drogas. Usou um pouco da droga no banheiro do bar e tinha mais um pouco no seu bolso, sobraram 06 porções consigo. Os policiais chegaram, mas não tentou deixar o local. Não estava traficando. Os policiais falaram que o que encontrassem seria dele. O menino que estava traficando tinha saído do local. Os policiais foram direito nele. É trabalhador e, com droga no bolso, ficou assustado. O menino que estava traficando saiu e ele ficou no local e foi abordado. Havia outras pessoas no bar. Foi abordado fora do bar, perto de uma mesa. Os policiais acharam mais drogas, mas não sabe em que local elas estavam, e disseram que era

dele. O dinheiro era proveniente do seu serviço. Infelizmente, é usuário de drogas. nunca tinha sido abordado pelos policiais. Faz uso de cocaína e não conseguia ficar sem consumi-la. tem duas internações.

A autoria delitiva restou comprovada nos autos. Vejamos.

O policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo contou estava em patrulhamento, em frente de um supermercado, onde é ponto de venda de drogas, com várias detenções anteriores, quando viram o réu. No local, tem um bar e um recuo, onde o bar coloca mesas e cadeiras, onde é o ponto de venda de drogas. O réu estava exatamente nesse recuo. Assim que avistou a equipe, o réu demonstrou nervosismo e tentou sair da abordagem. O réu viu a viatura, virou-se rapidamente, para não chamar a atenção, e tentou sair para a outra rua. Em busca pessoal, encontraram 32 porções de cocaína e dinheiro trocado. Indagado, ele confessou a ocorrência de tráfico e foi conduzido à Delegacia. Já tinha abordado o réu anteriormente no mesmo local, na posse de dinheiro trocado. Somente dessa vez ele tinha droga também. Nesse recuo, ficam várias pessoas do bar e da rua. O que chamou a atenção foi que o réu demonstrou nervosismo.

No mesmo sentido, o também policial militar Roger da Silva Olivêncio Mendes falou que estavam em patrulhamento, quando adentraram à avenida e visualizaram o réu próximo de um bar, em pé. Se ele estava com mais alguém, não perceberam. Quando viu a equipe, ele tentou sair rapidamente e foi abordado. Em revista pessoal, no bolso da blusa, havia droga e dinheiro, indagado, o réu falou que estava na prática do tráfico há algumas horas. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. já tinha abordado o réu no mesmo local anteriormente, mas nenhum ilícito do encontrado em seu poder, apenas dinheiro que ele disse ser proveniente do trabalho.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Na fase policial, o réu permaneceu calado. Em Juízo, o réu afirmou que tinha apenas 06 porções de cocaína consigo, que eram destinados ao seu próprio consumo. Negou que tivesse consigo o restante da droga, que não sabe onde os policiais encontraram.

Os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento de rotina, quando adentraram em rua conhecida por intenso comércio de drogas e visualizaram o réu num recuo de um bar. Ao avistar a aproximação da viatura, o réu tentou sair disfarçadamente do local, chamando a atenção da equipe policial. O réu foi abordado e, em revista pessoal, no bolso de sua blusa, encontraram 30 porções de cocaína e R\$ 226,00 em notas diversas. Questionado, informalmente, o réu confessou aos policiais que estava na prática do tráfico de drogas. Os policiais confirmaram que já tinham abordado o réu anteriormente no mesmo local, no entanto, ele apenas tinha consigo dinheiro.

Com efeito, temos duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, no sentido de que apenas 06 porções de cocaína estavam em seu poder, e a dos policiais militares, segundo os quais o entorpecente apreendido foi localizado no bolso do réu.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Consoante verifica-se dos autos, o réu foi abordado, porquanto apresentou comportamento suspeito, ao tentar deixar o local, quando avistou a viatura policial. Essa conduta já revela a ilicitude de sua conduta e confirma a versão dos policiais.

Além disso, a droga foi apreendida e sua quantidade não é diminuta, tudo a dar crédito à palavra das testemunhas.

De outro lado, o réu já tinha sido abordado no mesmo local e encontrado apenas com dinheiro.

De mais a mais, ambos os policiais apresentaram versão unânime, descrevendo situações que nem tinham sido mencionadas na fase policial, demonstrando a veracidade da sua informação.

Além disso, o policial Roger informou que a única pessoa que demonstrou nervosismo com a aproximação policial foi o réu, ou seja, o suposto moleque não fugiu do local, como quer fazer crer o réu.

Assim, cotejando a prova, devemos dar crédito ao depoimento seguro dos policiais militares que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro

lado, a palavra dos agentes policiais tem validade como prova, em especial como no caso concreto, quando conformada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Toda a prova, portanto, é suficiente para saber que a droga estava na posse do réu. Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que parte da droga era destinada ao seu próprio consumo, contudo, a prova confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas. Os policiais militares avistaram o réu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e ele, ao avistar a viatura, tentou sair disfarçadamente, levantando suspeita e justificando a abordagem.

A quantidade de droga apreendida (30 porções de cocaína) e sua forma de embalo (fls. 18) descrevem que não seria usada para consumo próprio, porquanto usuários não costumam manter essa quantia de drogas consigo, na via pública.

De outro lado, na posse do réu, havia dinheiro trocado, cuja procedência lícita não foi comprovada pelo réu.

Assim, a tentativa de fuga, o local da abordagem, a apreensão de significativa quantidade de droga, a forma de embalo da droga, a existência de dinheiro, o fato de o réu já ter sido abordado outras vezes no mesmo local; tudo evidencia que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a

consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos